



Roj: **STS 2881/2023 - ECLI:ES:TS:2023:2881**

Id Cendoj: **28079130022023100212**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso**

Sede: **Madrid**

Sección: **2**

Fecha: **21/06/2023**

Nº de Recurso: **6522/2021**

Nº de Resolución: **827/2023**

Procedimiento: **Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)**

Ponente: **JOSE ANTONIO MONTERO FERNANDEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAN 3097/2021,**
ATS 9369/2022,
STS 2881/2023

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

Sentencia núm. 827/2023

Fecha de sentencia: 21/06/2023

Tipo de procedimiento: R. CASACION

Número del procedimiento: 6522/2021

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 13/06/2023

Ponente: Excmo. Sr. D. José Antonio Montero Fernández

Procedencia: AUD.NACIONAL SALA C/A. SECCION 2

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José Golderos Cebrián

Transcrito por:

Nota:

R. CASACION núm.: 6522/2021

Ponente: Excmo. Sr. D. José Antonio Montero Fernández

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José Golderos Cebrián

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

Sentencia núm. 827/2023

Excmos. Sres. y Excmo. Sra.

D. José Antonio Montero Fernández, presidente

D. Francisco José Navarro Sanchís

D. Rafael Toledano Cantero

D. Dimitry Berberoff Ayuda

D.ª Esperanza Córdoba Castroverde

En Madrid, a 21 de junio de 2023.

Esta Sala ha visto el recurso de casación núm. 6522/2021, interpuesto por la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, con la representación que le es propia, contra sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) de la Audiencia Nacional, de fecha 31 de mayo de 2023, dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 925/2017, en el que se impugna la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 5 de julio de 2017, desestimatoria de las reclamaciones económico administrativas presentadas frente a los acuerdos de liquidación desestimatorios de las solicitudes de devolución de retenciones a cuenta de impuestos sobre la renta de no residentes, períodos 2011 y 2012.

Se ha personado en este recurso como parte recurrida la sociedad QATAR HOLDING LUXEMBOURG II, SARL, representado por la procuradora de los tribunales doña Gloria Teresa Robledo Machuca, bajo la dirección letrada de doña Silvia Paternain Osácar.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. José Antonio Montero Fernández.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Resolución recurrida en casación.

En el recurso contencioso-administrativo núm. 925/2017 la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) de la Audiencia Nacional, con fecha 31 de mayo de 2021, dictó sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

" **FALLAMOS** Que **estimando** el recurso contencioso administrativo interpuesto por **QATAR HOLDING LUXEMBOURG II, SARL**, y en su nombre y representación la Procuradora Sra. Dª Gloria Teresa Robledo Machuca, frente a la **Administración del Estado**, dirigida y representada por el Sr. Abogado del Estado, sobre **Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 5 de julio de 2017**, debemos declarar y declaramos no ser ajustada a Derecho la Resolución impugnada, y en consecuencia **debemos anularla** y la **anulamos**, así como los actos de los que trae causa, con imposición de costas a la demandada".

SEGUNDO. Preparación del recurso de casación.

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO recurso de casación, que por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) de la Audiencia Nacional tuvo por preparado mediante Auto de 10 de septiembre de 2021, que, al tiempo ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento a las partes.

TERCERO. Admisión del recurso.

Recibidas las actuaciones y personadas las partes, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, con fecha 15 de junio de 2022, dictó Auto precisando que:

"[...] **2º)** Las cuestiones que presentan interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consisten en:

1. Interpretar la cláusula antiabuso del artículo 14.1.h) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes a la luz de la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la carga de la prueba del abuso.

2. Determinar la calificación fiscal de las primas de asistencia a la Junta General de accionistas, en particular, si pueden calificarse de dividendos a los efectos de lo establecido en los artículos 22 y 10 del Convenio de Doble Imposición España-Luxemburgo .

3º) Identificar como normas jurídicas que, en principio, habrán de ser objeto de interpretación los artículos 14 del Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, así como los artículos 22 y 10 del Convenio entre el Reino de España y el Gran Ducado de Luxemburgo para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y para prevenir el fraude y la evasión fiscal y Protocolo anexo, hecho en Madrid el 3 de junio de 1986, en relación con el artículo 25.1.a) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

Ello sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, ex artículo 90.4 de la LJCA. [...]"

CUARTO. *Interposición del recurso de casación.*

La representación procesal de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO interpuso recurso de casación mediante escrito en el que termina suplicando a la Sala que "dicte sentencia por el que *estimándolo* case la sentencia recurrida y declare que:

-la carga de la prueba de la aplicación de la exención recogida en artículo 14.1.h) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes a la luz de la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y en consecuencia la demostración de que no es de aplicación la cláusula anti-abuso, corresponde al obligado tributario, que se beneficia de la misma.

-las primas de asistencia a la Junta General de Accionistas, pueden calificarse como dividendos a los efectos establecidos en los artículos 22 y 10 del Convenio de Doble Imposición España- Luxemburgo en relación con el artículo 25.1.a) de la LIRPF/2006, debiendo someterse a tributación y, por ende, a retención en el Estado en que resida la sociedad que pague los mismo.

Acto seguido, dicte fallo por el que se desestime el recurso contencioso administrativo interpuesto en la instancia confirmando la resolución del TEAC impugnada".

QUINTO. *Oposición al recurso de casación.*

La representación procesal de la sociedad QATAR HOLDING LUXEMBOURG II, SARL se opuso al recurso de casación interpuesto de contrario y suplica en su escrito a la Sala que "se dicte sentencia en la que se confirme la Sentencia dictada por la Sala de Instancia".

SEXTO. *Señalamiento para deliberación del recurso.*

Evacuados los trámites y de conformidad con lo previsto en el art. 92.6 de la LJCA, al considerar innecesaria la celebración de vista pública, se declararon conclusas las actuaciones, señalándose para votación y fallo del recurso el día 13 de junio de 2023, en cuya fecha han tenido lugar dichos actos procesales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. *Consideraciones a la vista del contenido de la sentencia de instancia, cuestión de interés casacional objetivo planteada y pronunciamientos de este Tribunal sobre la materia.*

En los Antecedentes de la presente sentencia se ha recogido el contenido de las cuestiones de interés casacional. La segunda será objeto de las consideraciones que más tarde se dirá. La primera coincide con las formuladas en los rec. cas. 6517/2021 y 6528/2021, en las que se fija la siguiente doctrina legal:

"La cuestión de interés casacional objetivo, formulada en estos términos "Interpretar la cláusula antiabuso del artículo 14.1.h) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes a la luz de la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la carga de la prueba del abuso", en atención a lo dicho en los fundamentos anteriores, debe responderse en el sentido de que a la vista de la jurisprudencia sentada por el TJUE representada por las tres sentencias que se han comentado, debe llevarnos a abandonar la doctrina jurisprudencial que se recoge en la sentencia de este Tribunal de 4 de abril de 2012, rec. cas.3312/2008, y posteriores, y la recogida en la sentencia de 3 de marzo de 2020, rec. cas. 5448/2018, y posteriores, al deber de ajustar e interpretar la cláusula antiabuso recogida en el citado art. 14.1.h) -modificado- conforme a las consideraciones que han quedado reflejadas en el cuerpo de esta sentencia, y, en consecuencia, procede fijar como doctrina que la carga de la prueba del abuso corresponde a la Administración Tributaria".

En el auto de admisión se recogieron las circunstancias más relevantes:

"1. La sociedad recurrente en la instancia percibió en los ejercicios 2011 y 2012 varios dividendos de fuente española, así como diferentes primas de asistencia a la junta general de accionistas, distribuidas y abonadas, respectivamente, por la sociedad Iberdrola, S.A. Dichos dividendos, así como las primas de asistencia, fueron sometidos a retención al tipo del 19% o 21% vigente en los respectivos ejercicios, de conformidad con lo dispuesto el TRLIRNR.

2. La sociedad solicitó y obtuvo, por medio del procedimiento regulado en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 13 de abril de 2000, la devolución del diferencial existente entre el tipo general de retención (19% o 21%, según el caso) establecido en la LIRNR y el tipo máximo de imposición sobre dividendos en el Estado de la fuente (15%) establecido en el CDI suscrito entre España y Luxemburgo.

3. En 19 de septiembre de 2013, la sociedad presentó ante la Administración tributaria -Delegación de la Agencia Estatal de Administración tributaria de Madrid- cuatro modelos 210 IRNR, siendo denegadas dichas solicitudes de devolución por las siguientes razones: (i) por el concepto de dividendos, al no ser de aplicación, a juicio de esa Administración, la exención Matriz-Filial, y (ii) por el concepto de primas de asistencia a juntas, al calificarse por esa Administración a aquellas como dividendos en vez de ganancia patrimonial.

4. Contra los referidos acuerdos denegatorios, la obligada tributaria interpuso reclamaciones económico-administrativas, que fueron desestimadas por el TEAC mediante resolución de 5 de julio de 2017, que fue asimismo recurrida ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional merced al recurso nº 925/2017, siendo estimado por sentencia de 31 de mayo de 2021, cuya *ratio decidendi* puede sintetizarse de la siguiente manera:

"(E)s evidente, por lo que hemos expuesto anteriormente, que la sociedad luxemburguesa desarrolla una actividad económica, consistente en la realización de inversiones en diversos países europeos, decide las inversiones y el destino de los beneficios, lo que la dota de una actividad económica que justifica su constitución, sin que pueda ser calificada de sociedad instrumental.

La Administración no ha aportado elemento probatorio o indiciario alguno que desvirtúe los anteriores datos.

Lo esencial es que la sociedad luxemburguesa actúa como un holding, gestiona la cartera y no existe elemento objetivo alguno del que deducir que se trate de una sociedad instrumental, bien al contrario, la gestión de las participaciones que realiza, hace imposible considerarla como entidad instrumental.

La estructura de control total único por una entidad catari, como se afirma en la contestación a la demanda, no es dato suficiente para entender que la sociedad es instrumental, porque tal planteamiento nos llevaría a privar de sustantividad propia en la gestión a cualquier filial participada al 100% por su matriz. Lo cual no es real en el mundo económico. Una filial puede actuar con autonomía aun reconociendo una unidad de decisión con su matriz o las sociedades del grupo.

No se observa artificiosidad en la constitución y funcionamiento en la entidad luxemburguesa, y la unidad de decisión respecto a la matriz, es lo propio de los grupos societarios, por ello, por sí misma, no es fundamento suficiente para afirmar la instrumentalidad.

Existen motivos económicos válidos.

La doctrina general contenida en la presente sentencia sigue la línea contenida en la nuestra sentencia de 21 de mayo de 2021, recurso 1000/2017 (...)

No podemos afirmar que las Primas de Asistencia permiten participar en los beneficios de la entidad, porque su causa no es la participación en dichos beneficios, sino que son cantidades abonadas por la sociedad a sus accionistas como gratificación por asistir a las Juntas Generales o Extraordinarias de la sociedad.

Se trata de una gratificación por un comportamiento de los accionistas, la asistencia a las Juntas, no de una participación en beneficios, por el carácter de accionista.

Pero, además, acierta la recurrente al señalar que España no trata, a efectos fiscales, de forma idéntica los dividendos y las Primas de Asistencia a Juntas, puesto que España deniega a las Primas de Asistencia la deducción por doble imposición, deducción que es la que caracteriza a los dividendos en un sistema tributario de créditos fiscales orientados a evitar la doble imposición de una misma renta como el nuestro. Y la necesidad de esta identidad de tratamiento se encuentra prevista en el artículo 10 del CDI España-Luxemburgo, como hemos visto.

La tributación de las Primas en sede del socio como rendimiento de capital mobiliario, que argumenta la Administración en fundamento a su planteamiento, no las convierte en dividendos, pues dentro de esta categoría de rendimientos se incluyen, también, los intereses de cuentas bancarias, bonos, obligaciones y, en general, títulos de renta fija, que no pueden ser calificado de dividendos ni participaciones en los beneficios de una entidad.

Por lo tanto es de aplicación el artículo 22 del CDI España-Luxemburgo, y tales Primas no pueden ser gravadas en España." (sic)".

Las alegaciones de las partes en este recurso de casación son similares a las realizadas en los recursos de casación a los que nos hemos referido y que sentaron la doctrina legal correcta. Bastaría en un caso similar, como aparentemente es este, con reproducir dicha doctrina para desestimar la pretensión de la parte recurrente.

Sin embargo, como bien observa la parte recurrida, la cuestión a dilucidar en el presente asunto no es jurídica, sino simple y llanamente fáctica, lo cual art. 87. Bis.1, "Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 93.3, el recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo se limitará a las cuestiones de derecho, con exclusión de las cuestiones de hecho", está excluida del ámbito de impugnación en el recurso de casación. Ya dijimos en la sentencia recaída en el rec. cas. 6528/2021, que -añadimos negritas- "Por ello, debemos de centrarnos a dar respuesta en los términos en los que se ha planteado el debate, y en esta línea ha de señalarse que tanto la AEAT como el TEAC y así se hace eco la sentencia, parten del presupuesto de que la regularización tuvo lugar, en lo que ahora interesa, **porque la obligada tributaria no "ha probado que se ha constituido por motivos económicos válidos, y no para disfrutar indebidamente del régimen previsto en dicha letra h)"**; esto es, sin perjuicio de que debamos de ratificar la sentencia de instancia por las razones que a lo largo de esta sentencia se irá desarrollando, en último término **la resolución de caso concreto, en todo caso, pasaría por dilucidar una cuestión de naturaleza probatoria y de a quién corresponde la prueba de acreditar la constitución de la entidad matriz por motivos económicos válidos y sobre quién debe recaer las consecuencias de no resultar acreditado dicho hecho**, de suerte que si en vez de haber negado la Inspección que la entidad no ha probado dicho presupuesto, hubiera acreditado la misma la falta de este requisito no podría haberse aplicado la exención reconocida; a criterio del Sr. Abogado del Estado, el artículo en disputa no sería contrario al Derecho europeo si la Inspección hubiera probado que el beneficiario efectivo reside en un tercer Estado, lo cual no es correcto porque es precisamente sobre este presupuesto sobre el que se establece la presunción que debe rechazarse, esto es, no es correcto la ecuación que parece desprenderse de su tesis de que siempre que el beneficiario efectivo sea la entidad del tercer Estado, se presume el abuso, cosa distinta, que es lo que se acaba de indicar, es que la Inspección hubiera probado que no concurre en la constitución de la entidad matriz un motivo económico válido". Pues bien, como se ha puesto de manifiesto al reproducir los términos del auto de admisión haciéndose eco de la sentencia de instancia, la Sala de instancia ha tenido por acreditado que la sociedad matriz no sólo fue constituida por un motivo económico válido, sino que a más a más, también desarrolla *"efectivamente una actividad empresarial directamente relacionada con la actividad empresarial desarrollada por la sociedad filial o tenga por objeto la dirección y gestión de la sociedad filial mediante la adecuada organización de medios materiales y personales"* -añadimos negritas-:

"Resulta acreditado del expediente administrativo, sin contradicción por parte de la Administración, las siguientes afirmaciones contenidas en la demanda, relevantes para resolver la actual controversia:

1.- La Sociedad es una entidad de responsabilidad limitada que fue constituida en Luxemburgo el 13 de agosto de 2009, cuyo objeto social es la adquisición de participaciones de cualquier compañía o empresa, así como la gestión de dichas participaciones (como se deduce del anexo nº 5 de los escritos de acompañamiento de los Modelos 210 de Devolución; i.e., como se desprende del contenido de la nota simple emitida por el Registro Mercantil luxemburgués -Registre de Commerce et des Sociétés-).

En el contexto de su actividad, la Sociedad, desde su constitución, ha venido realizando inversiones materiales en compañías de diferentes jurisdicciones, tales como: Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Portugal, España, Canadá, Japón y Marruecos, entre otras. Esta **continua actividad inversora** se inicia antes de la inversión en Iberdrola y se ha mantenido desde la misma, sin que haya ninguna conexión directa entre la constitución de la sociedad y la inversión en Iberdrola. Es decir, la Sociedad **constituye un vehículo permanente de inversión y la inversión en Iberdrola representa únicamente una parte de sus inversiones**.

2.- El peso relativo de la participación en Iberdrola a 31 de diciembre de 2011 en comparación con la totalidad del activo de la Sociedad, que ascendía en esa fecha a 6.672.129.627 de euros, es del 30,29% del activo total.

3.- La adquisición del primer paquete de acciones de Iberdrola se realizó por la Sociedad en marzo de 2011, esto es, casi un año y medio después de que se constituyese la Sociedad en Luxemburgo y de que realizase sus primeras inversiones en otras jurisdicciones diferentes de España.

La sociedad luxemburguesa realiza múltiples inversiones en varios países incluyendo a España. Es decir, la Sociedad es una sociedad holding de cartera que, como tal, realiza las actividades propias de una entidad de tales características.

4.- Los dividendos cobrados por la Sociedad distribuidos por Iberdrola constituyen únicamente una parte de las rentas obtenidas por QH Luxemburgo provenientes de sus múltiples inversiones, y no son, en su mayoría, tal como afirma la recurrente sin contradicción por parte de la Administración, redistribuidos por la Sociedad a su socio único Qatar Holding LLC, con residencia fiscal en Qatar. Por el contrario, **los ingresos obtenidos de sus inversiones, incluyendo los dividendos distribuidos por Iberdrola, son gestionados por la Sociedad con vistas a reinvertir u optimizar el uso de la caja a través de diferentes inversiones, tomándose y ejecutándose por el Consejo de Administración de QH Luxemburgo todas las decisiones relativas a la gestión de los recursos o a la repatriación de fondos**.

Es evidente, por lo que hemos expuesto anteriormente, que la sociedad luxemburguesa **desarrolla una actividad económica**, consistente en la realización de inversiones en diversos países europeos, decide las inversiones y el destino de los beneficios, lo que la dota de una actividad económica que justifica su constitución, sin que pueda ser calificada de sociedad instrumental.

La Administración no ha aportado elemento probatorio o indiciario alguno que desvirtué los anteriores datos.

Lo esencial es que la sociedad luxemburguesa actúa como un holding, gestiona la cartera y no existe elemento objetivo alguno del que deducir que se trate de una sociedad instrumental, bien al contrario, la gestión de las participaciones que realiza, **hace imposible considerarla como entidad instrumental**.

La estructura de control total único por una entidad catari, como se afirma en la contestación a la demanda, no es dato suficiente para entender que la sociedad es instrumental, porque tal planteamiento nos llevaría a privar de sustantividad propia en la gestión a cualquier filial participada al 100% por su matriz. Lo cual no es real en el mundo económico. Una filial puede actuar con autonomía aun reconociendo una unidad de decisión con su matriz o las sociedades del grupo.

No se observa artificiosidad en la constitución y funcionamiento en la entidad luxemburguesa, y la unidad de decisión respecto a la matriz, es lo propio de los grupos societarios, por ello, por sí misma, no es fundamento suficiente para afirmar la instrumentalidad.

Existen motivos económicos válidos".

A la vista de estos contundentes datos, y la acreditación que expresamente reconoce la sentencia de instancia de la existencia de motivos económicos válidos, aparte de que atendiendo a los términos en los que se pronuncia es fácil reconocer la concurrencia del carácter de beneficiario efectivo en la sociedad matriz, el planteamiento de la parte recurrente se nos muestra artificial y forzado, al punto que aún de acoger la tesis que preconiza, que no lo hacemos pues ha de estarse a la doctrina legal fijada, el resultado nunca le sería favorable al estar acreditado que sí existen motivos económicos válidos.

Dicho lo anterior, decae la segunda de las cuestiones de interés casacional objetivo. Como bien dice la parte recurrida, *"la prima de asistencia a las juntas de Iberdrola quedaría exenta de tributación en España ya sea porque tuviera la consideración de dividendo con derecho a beneficiarse de la Exención Matriz Filial o tuviera la consideración de "otras rentas" a los efectos del Convenio y solo pudiera ser gravado en el estado de residencia de la Sociedad. Por lo que en relación con este punto, la situación jurídico particular de la Sociedad debería respetarse en el sentido de que dichas rentas en ningún caso deberían ser objeto de gravamen en España"*. Así es, cualquiera que fuese la respuesta que recibiese la cuestión de interés casacional objetivo seleccionada, el resultado no podría ser otro que la confirmación de la sentencia impugnada y la desestimación de la pretensión de la recurrente, por lo que sin perjuicio de la corrección de la tesis recogida en la sentencia impugnada, no es labor de esta Sala ni finalidad del recurso de casación sentar doctrina legal en abstracto, desconectado del caso concreto, por lo que situados en el contexto del caso concreto, perdido el efecto útil necesario, no ha lugar a dar una respuesta a dicha cuestión.

SEGUNDO. Sobre las costas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 93.4 LJCA, no procede declaración expresa de condena a las costas del recurso de casación, al no apreciarse mala fe o temeridad.

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido :

Primero. Fijar los criterios interpretativos expresados en los rec cas. 6517/2021 y 6528/2021.

Segundo. Declarar no haber lugar al recurso de casación núm. 6522/2021, interpuesto por la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, contra sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) de la Audiencia Nacional, de fecha 31 de mayo de 2023, dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 925/2017, cuya confirmación procede.

Tercero. No hacer imposición de las costas procesales de esta casación.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.